

1500432-12.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... anotação característica do tráfico de entorpecentes. BRUNO afirmou que era locatário do imóvel. Nenhum suplemento alimentar foi localizado no local. O policial Osny fez coro às palavras do seu colega. Disse que várias porções de "crack", balanças de precisão, anotações do tráfico e petrechos para fracionamento da droga foram apreendidos sobre a mesa onde BRUNO encontrava-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500432-12.2022.8.26.0571 - Controle 2022/000477

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO EUFRASIO SILVA e outro

Data da Audiência:

20/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Bruno Eufrasio Silva. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Edson Prestes Rolim de Mello e Osny Benedito de Moraes Júnior arroladas pelas partes. Em seguida o réu Bruno Eufrasio Silva foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, Os réus foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois, em data anterior ao dia 22 de março de 2022, em horário e local incertos, associaram-se entre eles para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas, crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Além disso, no dia 22 de março de 2022, por volta das 17h30, na Rua Graciano de Campos, nº 184, Jardim Monte Santo, nesta cidade e comarca de Itapetininga, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 60 (sessenta) pedras de "crack", com peso líquido de 37,82g (trinta e sete gramas e oitenta e dois centigramas), drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O

réu BRUNO foi notificado pessoalmente (fls. 139) e o réu VALTER foi notificado por edital (fls. 160). Defesa prévias apresentadas (fls. 144/145 e 171/172). A denúncia foi recebida em 29/08/2022 (fls. 173/174). O réu BRUNO foi pessoalmente citado (fls. 191). VALTER aguarda o decurso do prazo da citação editalícia (fls. 198). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi BRUNO interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo auto de constatação (fls. 20/21) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 119/122). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu BRUNO disse que alugou um quarto no imóvel onde os fatos ocorreram. Falou que "Brian" deixou um sofá na habitação, dizendo que buscaria depois. Narrou que os policiais foram até o imóvel e, devidamente autorizados, realizaram buscas em seu quarto, ocasião em que encontraram sua balança, que era utilizada para pesar seus alimentos e suplementos. Contou que os policiais encontraram drogas no sofá deixado por "Brian" (fls. 08). Interrogado em Juízo, mudou sua versão. Disse que não estava associado a ninguém, mas efetivamente adquiriu o entorpecente para comercialização. Afirmou que VALTER estava de favor no local, ou seja, não tinha qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido. Admitiu que era o locador da residência. Não usa drogas. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que, anteriormente à data dos fatos, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico de drogas, restando acordado entre eles que ambos seriam responsáveis por picar e acondicionar drogas em embalagens para posterior venda dos entorpecentes. Então, no dia dos fatos, os denunciados estavam juntos na cozinha da residência localizada na Rua Graciano de Campos, nº 184, embalando pedras de "crack" para a comercialização. Todavia, policiais militares encontravam-se em diligências pelo local para dar cumprimento a mandados de prisão, momento em que avistaram Edilson Lopes, procurado. Edilson empreendeu fuga e acabou ingressando na casa em que estavam os denunciados. Os policiais saíram ao encalço de Edilson e, quando entraram na casa, encontraram os denunciados juntos na cozinha embalando porções de "crack", totalizando 60 pedras do referido entorpecente. Ainda na cozinha os policiais encontraram uma balança de precisão, embalagens vazias destinadas ao acondicionamento de drogas, anotações referentes à comercialização ilícita (fls. 16/17) e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais). Os denunciados foram presos em flagrante delito. Pois bem, o policial Edson afirmou que estavam em cumprimento a mandados de prisão. Então, ao localizar um dos alvos, a guarnição aproximou-se para abordá-lo. Essa pessoa correu e adentrou uma residência. Conseguiram detê-la dentro de um corredor e, pela janela da moradia, viram duas pessoas fracionando entorpecentes. Então, verificada a situação de flagrante delito, adentraram a moradia para averiguação dos fatos. Dentro das moradias estavam BRUNO e o corréu. Havia sobre a mesa em que estavam várias porções de "crack" que "picavam" e duas balanças de precisão. Foi apreendida mais droga dentro de um dos quartos da moradia. Também foi apreendida anotação característica do tráfico de entorpecentes. BRUNO afirmou que era locatário do imóvel. Nenhum suplemento alimentar foi localizado no local. O policial Osny fez coro às palavras do seu colega. Disse que várias porções de "crack", balanças de precisão, anotações do tráfico e petrechos para fracionamento da droga foram apreendidos sobre a mesa onde BRUNO encontrava-se debruçado. Também se lembrou da localização de uma porção de "crack" sobre um sofá. Não se lembra da apreensão de nenhum suplemento alimentar. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. É patente que o fato dos policiais terem encontrado os denunciados juntos, embalando pedras de "crack" na cozinhadado imóvel, a natureza extremamente nociva e a considerável quantidade de drogas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, parte já em porções individuais, prontos para a venda, além da localização de petrechos destinados à pesagem e embalagem de drogas e de anotações referentes à comercialização ilícita e, por fim, a quantia em dinheiro, demonstram que estavam associados para a prática do ilícito comércio de narcóticos. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Assim, os fatos narrados na inicial acusatória

foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 62/64). Cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a natureza e a grande quantidade de drogas apreendidas, o que evidencia que o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico seu meio de subsistência. Além disso, o acusado estava associado para a prática do narcotráfico, o que é absolutamente incompatível com a minorante em comento. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu BRUNO nos exatos termos da denúncia com a decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado Bruno foi denunciado juntamente com o corréu Valter (cujo processo está suspenso) e está sendo processado como incurso no artigo 33 e 35 caput da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I- DA ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA. Desvio causal. Ausência de nexo com o fato originário: O réu foi preso dentro da residência localizada na Rua Graciano de Campos, nº 184, Jardim Monte Santos, local onde foram encontrados os entorpecentes, porque, de acordo com as testemunhas, policiais militares, estavam em operação e saíram para dar cumprimento a mandados de prisão. Apontaram que receberam notícias de que Edilson Lopes estaria no bairro Jd. Monte Santos e como estavam com mandado de prisão contra ele para lá se deslocaram. Em patrulhamento pelo bairro avistaram Edilson e ao se aproximar ele correu sendo perseguido até que entrou no imóvel onde acabou detido no corredor. Abordaram Edilson Lopes na residência para onde fugiu, e acabaram por surpreender os acusados Bruno e Valter na cozinha da casa, embalando porções de crack para venda. Disseram que na cozinha onde os dois estavam localizaram uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas utilizadas para embalar a pedra de crack e acharam também algumas pedras de crack já embaladas e outras sendo embaladas. Portanto, evidente a ausência de autorização judicial específica para restrição de garantia constitucional no caso da nova infração descoberta, que era desconhecida da autoridade. A ordem judicial autorizando a prisão de terceira pessoa estava relacionada a outro crime, de modo que qualquer outra prova relacionada a fato diverso se considera obtida sem respaldo legal. É que o juiz só havia autorizado a medida invasiva ou restritiva para o delito originário. Trata-se de delimitar o âmbito de abrangência da constrição concedida, não sendo possível ampliar a interpretação quando se trata de garantia constitucional, nem tampouco admitir violação de direito constitucional, sem prévio conhecimento e autorização por parte do Poder Judiciário. Ao cumprir mandado de prisão de terceiro, em determinada residência, rompe-se a garantia

fundamental da inviolabilidade domiciliar (CF, artigo 5º, XI). Por essa razão, a utilização da prova fortuita deve necessariamente guardar nexo de pertinência lógica com o fato originalmente investigado, sob pena de excederem-se os limites constitucionais. Sustentando tal posição, Aury Lopes Jr. argumenta: "Em que pese a maior parte da doutrina que trata do tema admitir que a prova obtida (mediante desvio causal) seja o starter de uma nova investigação, há que se ponderar o seguinte: se usarmos a prova obtida com desvio causal, ainda que a título de conhecimento fortuito, estaremos utilizando uma prova ilícita derivada. Isso gera um paradoxo insuperável: a prova ilícita (despida de valor probatório, portanto) em um processo, mas vale (ria) como notícia-crime em outro... Ora, partindo do Princípio da Legalidade, a investigação tem que se iniciar a partir de prova lícita e não de uma prova ilícita, sob pena de contaminarmos todos os atos praticados na continuação" (Direito Processual Penal, 18ª edição, ed. Saraiva Jur, 2021, p. 439.). Assim, diante da inexistência de nexo causal entre a investigação original (busca de pessoas procuradas/foragidas) e a nova infração descoberta, as provas obtidas no interior da residência devem ser consideradas ilícitas, absolvendo-se o acusado com base no art. 386, III do CPP. II- DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI

Nº 11.343/06. Da absolvição por falta de provas. Ausência de provas de permanência e estabilidade. O delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 não restou minimamente configurado no caso. Não há, nos autos, qualquer indício no sentido de que o réu teria se associado ao corréu para o cometimento do tráfico de drogas. A acusação não foi precedida de investigações que comprovassem o elo subjetivo entre eles ou entre algum deles. O próprio policial Edson relatou sequer se recordar de ter abordado os dois acusados anteriormente. Além disso, não há qualquer informação nos autos acerca de investigação prévia, campanas, etc. De outra parte, posto que se considere que os réus teriam, em unidade de desígnios, cometido o tráfico, não há nos autos qualquer prova ou indício de que cometessem a empreitada criminosa de forma habitual, sendo que é inerente ao tipo (art. 35 da Lei de Drogas) tal associação, não bastando o simples "ajuntamento eventual". Ou seja, associar-se significa unir-se de maneira estável com a finalidade de praticar diversos crimes. A característica da associação é a permanência e a estabilidade do vínculo. Há a necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O STF decide em consonância com o sobredito, vejamos: "A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes, dispensa o elemento mais característica das figuras penais de associação para delinquir, qual seja, a predisposição da *societas sceleris* à prática de um número indeterminado de crimes: para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama á sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada." (STF, RHC 75236/AM, 1ª Turma, Rel. Sepúlveda Pertence, DJU 01.08.1997). No que toca ao delito de associação, a conduta expressa no artigo exige permanência, o que definitivamente não houve no caso em tela. Em harmonia com esse entendimento, confira-se o posicionamento judicioso dos respeitadores doutrinadores Guilherme Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller: "O mero planejamento para uma eventual conduta de tráfico em conjunto fica evidentemente absorvido pelo próprio crime de tráfico, que exaure o potencial lesivo do planejamento, sem merecer relevância penal autônoma. Como não é possível crime sem lesão ou risco ao bem jurídico, a única interpretação viável e constitucional do artigo é que, para a tipificação da conduta, persiste sendo necessário a finalidade e permanência, como no crime de quadrilha do Código Penal, diferenciando-se daquela figura pelo elemento subjetivo (não basta querer praticar qualquer crime, mas apenas os previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 da Lei de Drogas) e pelo número de agentes (para o Código Penal, um mínimo de quatro, enquanto na Lei de Drogas são suficientes dois)". Diante do exposto, não tendo sido comprovada a associação estável e em virtude do respeito ao princípio *in dubio pro reo*, é imperiosa a absolvição dos acusados no que tange ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. IV- DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Afastada a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra "dedicação às atividades criminosas", faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades

criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida". (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 - grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. V- TESES SUBSIDIÁRIAS: Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; (ii) seja aplicada a atenuante da confissão espontânea; (iii) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, já que presentes os requisitos legais; (iv) seja fixado o regime aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, "c", § 3º, do CP, bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ; (v) seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal; (vi) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) - art. 387, § 1º, do CPP, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das cautelares arroladas no art. 319 do CPP. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. BRUNO EUFRASIO SILVA e VALTER FERNANDO DOMINGUES PRESTES, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 33, "caput", e no art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. De acordo com a denúncia, em data anterior ao dia 22 de março de 2022, os réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas. Em 22 de março de 2022, por volta das 17 h e 30 min, na Rua Graciano de Campos, n. 184, Jardim Monte Santo, nesta Cidade e Comarca, os Réus, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituenta fora constituída, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, sessenta pedras de "crack", com peso de 37,82 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O Acusado Bruno Eufrasio Pires foi notificado, fls. 139, e apresentou defesa preliminar, fls. 144/145. O Acusado Valter Fernando foi notificado por edital, fls. 160, e apresentou defesa, fls. 171/172. A denúncia foi recebida, fls. 173/174. A seguir, o Acusado Bruno Eufrasio foi citado pessoalmente, fls. 191, e o Réu Valter Fernando, por edital, fls. 199. Durante a instrução, foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Réu Bruno Eufrasio (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Acusado Bruno Eufrasio; por outro lado, a Dra. Defensora Pública, insistiu na absolvição e na aplicação de benefícios. É o relatório. I - FUNDAMENTO. Inicialmente deixo registrado que esta sentença é adstrita ao Réu BRUNO EUFRASIO SILVA, na medida em que o processo foi suspenso em face do Acusado Valter Fernando Domingues Prestes. Afasto a preliminar. Com efeito, os policiais militares executavam o cumprimento do mandado de prisão e, na tentativa de prender Edilson, eles tiveram que ingressar na casa do Réu Bruno porque Edilson, embora não residisse na casa, invadiu o imóvel e os policiais estavam em seu encalço, e, diga-se de passagem, os policiais tinham que assim agir até mesmo para prender Edilson e para coibir a invasão de domicílio. Nestes termos as testemunhas viram os entorpecentes e a partilha. Segundo o art. 5º, inciso XI, a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito ou durante o dia, por determinação Judicial (grifo nosso). Portanto há autorização para ingresso em residências

durante o dia ou noite em caso de flagrante delito. Segundo disposição do art. 283 "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva". Oportuno ressaltar que os policiais não ingressaram na residência sem qualquer informação, de forma aleatória; seguiam no encalço de Edilson e, ao entrarem à casa, como forma de coibir a invasão de domicílio pelo fugitivo, viram os entorpecentes e a partilha destes para o comércio ilícito. Assim, havia fundada suspeita para a abordagem e vistoria da casa, onde, de fato, encontraram entorpecentes destinados ao comércio, em situação de flagrante delito, na medida em que o crime de tráfico de entorpecentes é permanente. O caso concreto se amolda ao permissivo constitucional. A pretensão punitiva estatal é procedente. Analiso a prova coligida. Às fls. 14/15 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: duas balanças de precisão; R\$ 40,00; uma tesoura; uma lâmina gilete; duas folhas de papel com anotações; diversos sacos plásticos; um telefone celular, marca Samsung, modelo J700; e 60 pedras de "crack", com peso de 40,97. Às fls. 119/122 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo em Substância Entorpecente n. 90.722/2022 no qual consignou: "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores". Edson Prestes Rolim de Mello e Osny Benedito de Moraes Júnior, policiais militares, testemunhas, disseram que estavam em operação e saíram para cumprir mandados de prisão; souberam que Edilson Lopes estava no bairro Monte Santo e para lá se deslocaram, e, em patrulhamento pelo local, depararam-se com Edilson, o qual, ao ver a viatura, empreendeu fuga e ingressou em um imóvel, onde os policiais encontraram os réus Bruno e Valter, os quais embalavam porções de entorpecentes; na cozinha onde se encontravam, os policiais localizaram uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas, algumas porções de "crack" já embaladas e outras a serem embaladas; no quarto de Valter os policiais localizaram uma pedra grande de "crack". Bruno Eufrásio Silva, Réu, ao ser interrogado, disse que, em virtude de dificuldades financeiras, adquiriu drogas para venda, mas não havia associação com Valter, o qual apenas passava alguns dias na sua casa, o que fez para ajudá-lo. Conforme se verifica, analisadas as circunstâncias da prisão infere-se a prática do tráfico de entorpecentes, pois outra conclusão não se chega após a análise da quantidade de drogas, além do fato de parte das drogas já estar embalada para o comércio. Ademais, havia balança de precisão, comumente usada para pesagem das drogas, além de sacos para embalagem dos entorpecentes a serem vendidos, e contabilidade do tráfico. Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu Bruno guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, analisando-se o conjunto probatório, conclui-se no sentido de que falta a presença de elementos de convicção confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os Réus, na medida em que os policiais não procederam a maiores investigações. O simples fato de o Acusado Bruno ter sido surpreendido no comércio espúrio, por si só, não demonstra a prática do delito do art. 35, da Lei de Entorpecentes, pois o liame estável com o Réu Valter não está demonstrado e, de fato, é possível que Valter lá estivesse de forma absolutamente temporária, e tenha, somente naquela oportunidade, se dedicado ao comércio ilícito, já que foi visto na manipulação das drogas e, no seu quarto, havia uma pedra de "crack". Como é cediço, para a condenação, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito e, para tanto, não provas contraditórias e pouco esclarecedoras a respeito da responsabilidade dos

agentes. Essas circunstâncias fazem surgir ao Juiz dúvida invencível que, no processo penal, resolve-se em favor da defesa, por aplicação do princípio *in dubio reo*, e impõe o reconhecimento do *non liquet*, com a absolvição do Réu, no que diz respeito ao delito estatuído pelo art. 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. BRUNO EUFRASIO SILVA:ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006: - Art. 59, “caput”, do Código Penal: Considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena – base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu confessou o delito, logo faz jus a atenuante da letra “d”, do inc. III, do art. 65, do Código Penal, com redução de 1/6. Todavia, na segunda etapa, a atenuante da confissão não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. - Art. 68, parte final, do Código Penal: O Réu é primário e as circunstâncias judiciais são positivas, portanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, considerando-se a quantidade e a diversidade dos entorpecentes. Destarte, torno definitiva pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias – multa, no piso. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada, e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de final de semana. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar BRUNO EUFRASIO SILVA, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias – multa, no piso, por incidir no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006. Absolvo-o da acusação de incidir no art. 35, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e

limitação de fim de semana. Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que o Réu não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento da família. Decreto o perdimento dos bens e dos valores apreendidos. O Réu respondeu em liberdade ao processo e poderá interpor eventual recurso nessa condição, insubsistentes as razões do encarceramento. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 20 de outubro de 2022. Eu, (RAFAEL MORAIS DA SILVA), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA